

1502486-32.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502486-32.2022.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502486-32.2022.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

MATHEUS DE JESUS ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 17h10min, na Rua Oito, altura do numeral 268, Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, transportou e manteve em depósito para entrega a consumo de terceiro, 122 porções de "crack", 108 porções de cocaína e 87 porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que, na data dos fatos, guardas municipais patrulhavam o local dos fatos, quando observaram que o réu portava uma sacola plástica. Ao notar a aproximação da viatura, Matheus empreendeu fuga e jogou a sacola no chão.

Diante dessa conduta, os agentes públicos acompanharam o acusado e, logo em seguida, efetuaram sua interceptação. Realizada revista pessoal, em poder dele nada foi encontrado. Contudo, no interior da sacola plástica que o réu jogou ao solo, foram localizadas 21 porções de maconha, 56 porções de "crack" e 18 porções de cocaína.

Questionado, Matheus admitiu informalmente a traficância, inclusive informando que guardava mais drogas sob um veículo estacionado na via pública.

Os guardas municipais diligenciaram no local indicado pelo acusado e localizaram uma sacola plástica contendo 66 porções de maconha, 66 porções de "crack" e 90 porções de cocaína.

Assim, pela quantidade e variedade das substâncias entorpecentes e circunstâncias da apreensão, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a não aplicação do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e a imposição de regime inicial fechado.

A defesa, em preliminar, arguiu a ilicitude das provas, porquanto provenientes da ilegalidade da prisão do acusado, feita por guardas municipais, os quais não tem poder de polícia. No mérito, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Em caso de entendimento diverso, requereu o que segue: desclassificação do delito para uso próprio; fixação da pena-base no patamar legal; reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial; aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo; imposição de regime inicial diverso do fechado; substituição da corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer solto. RELATADO.

DECIDO.

A preliminar suscitada não merece guarida.

Com efeito, não há falar em nulidade na abordagem do réu realizada pelos guardas municipais, vez que quando esses agentes interceptam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem se omitir diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, "(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que ensejou a presente ação penal.

Importante observar, outrossim, que, no caso dos autos, não foram extrapoladas as funções típicas da Guarda Municipal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a busca e apreensão feita a partir de fundada suspeita de flagrância, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, é permitida à Guarda Civil Municipal, não havendo abuso de função.

Nesse sentido, "1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC nº 667.413/SP, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/6/2021).

E mais, "(...) Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeitas para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes" (STJ, HC 742.941/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), DJe 16/08/2022).

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios.

Oportuno, ainda, frisar que "em processo penal, vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)" (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Afastada a preliminar, no mérito, diante da prova existente verifica-se que a denúncia deve ser julgada procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 33/36 e 75/77), provisório e definitivo, os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu confessou a traficância nos termos da denúncia, dizendo que venderia as drogas na "Biqueira da Escadinha", localizada nas proximidades da UPA do Varjão, no período das 15h00min às 6h00min e receberia quantia de R\$ 50,00 a cada 30 porções vendidas. Afirmou que ao avistar a viatura da Guarda Municipal, saiu correndo carregando o tóxico, mas livrou-se dele durante a fuga. Ao ser detido, admitiu que venderia os entorpecentes que carregava e indicou o local onde havia escondido o restante deles. Em Juízo, retratou-se, dizendo que estava no local dos fatos para comprar drogas. Não tentou correr ao avistar os guardas municipais. Acabou detido e preso. Já havia sido interceptado pelos agentes municipais.

Sucedendo que tal negativa restou isolada nos autos e não merece credibilidade,

cumprindo observar que a confissão policial, quando corroborada por outros elementos de convicção, tem grande valor probatório.

Importante frisar que, na fase inquisitiva, o réu confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes, informando até o preço das drogas e quanto receberia a título de pagamento. Depois, em Juízo, retratou-se.

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete, que a confissão policial merece maior credibilidade que a sua retratação judicial, quando aquela tem algum amparo dos demais elementos de prova dos autos (cf. Código de Processo Penal Interpretado, 10ª ed., Atlas, 2003, nº 200.2, pág. 544).

Nesse sentido julgado do Tribunal de Justiça, “é inegável o valor probatório da confissão policial entrosada com outros elementos de convicção” (Apelação Criminal nº. 0005974-94.2008.8.26.0274, Rel. Desembargador Penteado Navarro).

Em outras palavras, para que a revogação da confissão tenha significado “deve o acusado fundamentá-la em forma a convencer o julgador de ter sido fantasista a confissão” (Eduardo Espínola Filho, Código de Processo Penal Anotado, 1ª ed., Saraiva, 2000, pág. 206).

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas Erick Medeiros Honório e Jonas Botelho Marestoni, guardas municipais que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas em poder do réu. Relataram, ainda, que o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga por aproximadamente 20 metros e jogou uma sacola ao solo. Ao ser detido, Matheus confessou a traficância informalmente e apontou o local onde estava o restante do entorpecente. Todas as drogas estavam embaladas de forma semelhante. As palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação.

Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição, bem como vão de encontro à confissão extrajudicial ofertada pelo acusado. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados que não conheciam, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, “A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

Como se vê, o conjunto probatório amalhado aos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nos exatos termos da inicial acusatória, posto que evidenciado o intuito de mercancia.

Para tanto, deve ser ressaltado as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas e como se deu a prisão do agente.

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Ensina Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a

quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, nº 5, pág. 96).

Inviável a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos em poder do réu.

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação. Ante o exposto, afastada a preliminar, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu MATHEUS DE JESUS ROCHA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, no percentual de 1/5 (um quinto), somando 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ante a variedade e quantidade de tóxico apreendida, além de responder a outras ações penais, por delito idêntico e com condenação em primeira instância.

Note-se que a "Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006" (cf. STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-094, 15/05/2012).

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão a sanção retorna ao mínimo previsto em lei.

Observe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea realizada perante a autoridade policial, ainda que retratada em juízo, desde que ela tenha, em conjunto com outros meios de prova, embasado a condenação (cf Habeas Corpus nº 90.470/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 17/03/2008).

Não é caso de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, o que demonstra a dedicação do acusado ao crime.

A sanção privativa de liberdade ora aplicada será cumprida em regime fechado, uma vez que se trata de crime gravíssimo, eis que a real intenção do traficante é amealhar o maior número de vítimas, comprometendo toda a sociedade.

Observe-se, por oportuno que mesmo a fixação da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é fator determinante para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando a última parte do artigo em comento "estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" tem-se que o regime inicial fechado é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato, uma vez que a conduta do acusado colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.

O réu não poderá apelar em liberdade, porquanto permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra.

Assim, fica o réu MATHEUS DE JESUS ROCHA, condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 8 de dezembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito